

제25장

증거조사

제1절 총 설 2

제2절 증거조사절차 13

제3절 증거보전 43

제1절 총 설

1. 의 의

분쟁을 해결하는 수단으로서의 재판과정은 사실을 확정하는 과정과 법규를 해석·적용하는 과정으로 나누어 볼 수 있다. 후자에 있어서는 법관이 전문가이므로 원칙적으로 법규의 존재사실을 증거에 의하여 확정할 필요는 없다. 그러나 전자, 즉 사실을 확정하기 위하여는 이를 위한 자료가 있어야 하는데 이것이 곧 증거이다.

증거라는 개념에는 증거방법, 증거자료, 증거원인 등 여러 의미가 있다.

(1) 증거방법은 법원이 사실의 존부를 확정하기 위하여 조사하는 대상이 되는 유형물을 말한다. 증거방법 중에서 증인과 감정인 및 당사자는 인적증거(인증: 人證)이고, 문서와 검증물 등은 물적증거(물증: 物證)이다.

(2) 증거자료는 증거방법을 조사하여 얻은 내용을 말한다. 문서의 기재내용·증언·검증결과·감정결과·조사촉탁결과·당사자신문결과 등이 그것이다.

(3) 증거원인은 법관의 심증형성의 원인이 된 자료나 상황을 말한다. 증거자료와 변론 전체의 취지가 이에 해당한다.

2. 증거능력과 증거력

가. 증거능력

증거방법으로서 증거조사의 대상이 될 수 있는 자격을 증거능력이라고 한다. 예컨대 법정대리인은 당사자신문의 대상일 뿐 증인신문의 대상이 될 수 없고(민소 367조, 372조), 기피신청이 받아들여진 감정인은 감정을 할 자격을 상실하며(336조, 337조), 선서하지 않은 감정인에 의한 감정결과는 증거가 될 수 없다(대법원 1982. 8. 24. 선고 82다카317 판결). 즉 증거능력이 부정된다. 또한 불법검열·불법감청에 의하여 취득한 우편물이나 전기통신의 내용,

공개되지 아니한 타인간의 대화를 녹음 또는 청취한 내용은 재판절차에서 증거로 사용할 수 없다(통비 4조, 14조). 제3자가 전화통화 당사자 일방의 동의를 받고 그 통화 내용을 녹음하였다 하더라도 그 상대방의 동의가 없었던 이상 전기통신의 감청에 해당하여 통신비밀보호법 3조 1항 위반이 되고, 이와 같이 3조 1항을 위반한 불법감청에 의하여 녹음된 전화통화의 내용은 4조에 의하여 증거능력이 없다(대법원 2021. 8. 25. 선고 2021다236999 판결).

민사소송법은 자유심증주의를 채택하고 있으므로(민소 202조), 위와 같은 법률상 예외를 제외하면 증거능력의 제한은 없다. 따라서 소제기 후에 계쟁 사실을 증명하기 위해 작성한 사문서도 증거능력이 있고(대법원 1992. 4. 14. 선고 91다24755 판결), 전문증거도 증거능력이 있으며, 어느 일방이 상대방과의 대화를 비밀리에 녹음한 녹음테이프도 증거능력이 있다(대법원 1999. 5. 25. 선고 99다1789 판결).

나. 증거력

증거자료가 요증사실의 인정에 기여하는 정도를 증거력(증명력·증거가치)이라고 한다. 이것은 형식적 증거력과 실질적 증거력의 두 단계로 나누어지는데, 특히 서증의 경우에 중요한 의미가 있다. 성립의 진정, 즉 증명자가 주장하는 특정인의 의사·판단 등의 표현이라고 인정될 수 있는지가 증명되지 않은 문서는 형식적 증거력이 없기 때문에 실질적 증거력의 유무를 따질 것도 없이 증거로 삼을 수 없게 된다. 실질적 증거력은 논리칙과 경험칙에 따라 법관이 자유로운 심증으로 판단한다.

3. 증거의 분류

가. 본증과 반증

본증은 당사자가 자기에게 증명책임이 있는 사실을 증명하기 위하여 제출하는 증거를 말하고, 반증은 상대방이 증명책임을 지는 사실의 증명을 저지

하기 위하여 제출하는 증거를 말한다.

나. 직접증거와 간접증거

직접증거는 주요사실의 존부를 증명하기 위한 증거를 말하고, 간접증거는 주요사실의 존부를 인정하는 자료가 되는 간접사실 또는 증거의 가치판단에 관한 보조사실의 존부를 증명하기 위한 증거를 말한다.

다. 증명과 소명

증명은 어느 사실의 존부에 관하여 법관으로 하여금 확신을 얻게 하기 위하여 증거를 제출하는 당사자의 노력 또는 그로 인하여 법원이 그러한 확신을 얻은 상태를 말하고, 소명은 증명에 비하여 한 단계 낮은 개연성, 즉 대개 그럴 것이라는 추측 정도의 심증을 얻게 하기 위하여 증거를 제출하는 당사자의 노력 또는 그로 인하여 법원이 그러한 추측을 얻은 상태를 말한다.

민사소송법 기타 법률에 소명으로 족하다는 특별한 규정이 있는 경우(대표적인 경우가 소송비용액에 관한 민소 110조 2항, 소송구조에 관한 민소 128조 3항, 가압류·가처분에 관한 민집 279조 2항, 301조임)를 제외하고는, 사실을 인정하려면 원칙적으로 증명에 의한다. 소명은 증명의 경우와는 달리 즉시 조사할 수 있는 증거방법에 의하여야 하며, 법원은 당사자 또는 법정대리인으로 하여금 보증금을 공탁하게 하거나 그 주장이 진실하다는 것을 선서하게 하여 소명에 갈음할 수 있다(민소 299조 1항, 2항). 서증이 증명을 위한 자료로 제출되었을 때에는 “갑 제○호증”, “을 제○호증” 등으로 표시하고(민소규 107조 2항), 소명자료로 제출되었을 때는 “소갑 제○호증”, “소을 제○호증” 등으로 표시한다.

라. 엄격한 증명과 자유로운 증명

엄격한 증명은 법률에서 정한 증거방법에 대하여 법률이 정한 절차에 의

하여 증거조사를 실시하는 증명을 말하고, 자유로운 증명은 증거방법과 증거조사의 절차에 관하여 법률의 규정으로부터 해방되는 증명을 말한다.

소송물인 권리관계의 기초사실은 엄격한 증명을 요함에 대하여, 자유로운 증명은 간이·신속을 요하는 결정절차나 직권조사사항에 제한적으로 허용된다. 관습법의 인정, 소송목적의 값의 산정은 자유로운 증명으로 가능하다.

4. 증명의 대상

가. 요증사실

증명의 대상으로서의 요증사실에는 주요사실(요건사실)은 당연히 포함되고, 간접사실과 보조사실도 그에 의하여 주요사실을 증명하려고 하는 때에는 요증사실에 포함된다.

나. 법 규

법규의 존부확정이나 적용은 법원의 직책이므로 일반적인 법규의 존재사실은 증명의 대상이 되지 않는다. 국제사건에 관하여 국제사법에 따라 준거법으로 정해진 외국법의 내용은 법원이 직권으로 조사·적용하여야 하고, 이를 위하여 당사자에게 그에 대한 협력을 요구할 수 있는데(국제사법 18조), 그 방법과 절차는 자유로운 증명, 즉 법원이 합리적이라고 판단하는 방법에 의하여 조사하면 충분하고 감정인의 감정이나 전문가의 증언만으로 확정할 필요는 없다(대법원 1992. 7. 28. 선고 91다41897 판결). 외국적 요소가 있는 사건이라면 준거법과 관련이 없더라도 법원으로서의 적극적으로 석명권을 행사하여 당사자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하거나 필요한 자료를 제출하게 하는 등 그 법률관계에 적용될 국제협약 또는 국제사법에 따른 준거법에 관하여 심리, 조사할 의무가 있다(대법원 2025. 3. 27. 선고 2021다242185 판결). 우리나라가 가입한 국제협약은 일반적으로 민법이나 상법 또는 국제사법보다 우선적으로 적용되고, 그 국제협약이 스스로 적용을 배

제하거나 규율하고 있지 않은 사항에 해당하는 법률관계에 대해서는 국제사법에 따라 결정되는 준거법이 적용되기 때문이다(대법원 2024. 3. 12. 선고 2023다288772 판결 등 참조). 다만 소송 과정에서 적용될 외국법규에 흠결이 있거나 그 존재에 관한 자료가 제출되지 아니하여 그 내용의 확인이 불가능한 경우 법원으로서 법원(法源)에 관한 민사상의 대원칙에 따라 외국 관습법에 의할 것이고, 외국 관습법도 그 내용의 확인이 불가능하면 조리에 의하여 재판할 수밖에 없다(대법원 2000. 6. 9. 선고 98다35037 판결 등).

다. 경험칙

‘경험칙’이란 인간의 경험에서 귀납적으로 얻어지는 사물에 대한 지식이나 법칙을 말한다. 즉 같은 종류의 많은 사실을 경험한 결과 얻은 일반적인 결론을 경험칙이라고 한다. 경험칙에는 일상적·상식적인 것과 전문적인 것이 있는데, 일상적·상식적인 경험칙은 이를 증명할 필요가 없다. 전문적인 경험칙에 관하여는 반드시 증명할 필요는 없고 법관이 문헌을 조사하는 등의 방법으로 알 수 있다는 견해도 있으나, 소송당사자가 감정 등의 방법으로 이를 증명하여야 한다는 것이 통설·실무이다.

5. 증명의 필요가 없는 사실

가. 재판상 자백한 사실

(1) 의 의

‘재판상 자백’이란 변론 또는 변론준비절차에서 자기에 불리한 상대방의 주장사실을 진실한 것으로 인정하는 당사자의 진술을 말한다. 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 있다고 인정하기에 충분하지 않다(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다280781 판결). 법원에 제출되어 상대방에게 송달된 답변서나 준비서면에 자백에 해당하는 내용이 기재되어 있는 경우, 그것이 변론기일이나 변론준비기일에서 진술 또

는 진술간주되어야 재판상 자백이 성립한다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2014다 229870 판결). 소송행위로서의 진술을 의미하므로 당사자신문 중에 상대방의 주장과 일치하는 진술을 하더라도 이는 증거자료에 그칠 뿐 재판상 자백으로 되지 아니하고(대법원 1978. 9. 12. 선고 78다879 판결), 다른 소송에서 한 자백은 하나의 증거원인이 될 뿐 민사소송법 288조에 의한 구속력이 없다(대법원 1996. 12. 20. 선고 95다37988 판결).

당사자 일방이 상대방의 주장에 앞서서 자기에게 불이익한 사실을 진술한 선행자백의 경우에, 상대방이 이를 원용하거나 그에 상응하는 주장을 한 때에는 자백의 효력이 있으나(대법원 1988. 12. 13. 선고 87다카3147 판결), 상대방이 원용하기 전까지는 그 진술을 철회하고 이와 모순되는 진술을 자유로이 할 수 있으며 이때에는 소송자료에서 제거되므로 그 후에는 원용할 수 없다(대법원 1992. 8. 14. 선고 92다14724 판결).

(2) 대 상

자백의 대상이 될 수 있는 것은 구체적 사실에 한하고, 소송물의 전제가 되는 권리관계 및 법규나 경험칙 또는 이들을 적용하여 정하여지는 법률상의 효과는 그 대상이 아니다(대법원 1992. 2. 14. 선고 91다31494 판결). 그러나 예컨대 증명사항인 매매 또는 임대차의 성립을 상대방이 인정한다고 진술하는 경우에 이는 상식적인 용어가 되다시피 한 단순한 법률상의 용어로 압축하여 표현한 것이므로 자백의 효력이 발생하고(대법원 1984. 5. 29. 선고 84다122 판결), 소유권에 기한 이전등기말소청구소송에서 피고가 원고 주장의 소유권을 시인하는 경우에 이는 소유권의 내용을 이루는 사실에 대한 진술로 볼 수 있으므로 자백의 효력이 발생한다(대법원 1989. 5. 9. 선고 87다카 749 판결). 다만 이는 사실에 대한 법적 추론의 결과에 대하여 의문의 여지가 없는 단순한 법개념에 대한 자백의 경우에 한하여 인정되는 것이고, 추론의 결과에 대한 다툼이 있을 수 있는 경우에는 이른바 권리의 자백으로서 법원이 이에 기속을 받을 이유는 없으므로(대법원 2007. 5. 11. 선고 2006다

6836 판결), 사안에 따라 유의할 필요가 있다. 법률상 유언이 아닌 것을 유언이라고 시인하였다 하여 그것이 곧 유언이 될 수 없고 이와 같은 진술은 민사소송법상의 자백이 될 수 없다(대법원 2001. 9. 14. 선고 2000다66430, 66447 판결). 이행불능에 관한 주장은 법률적 효과에 관한 진술을 한 것에 불과하고 사실에 관한 진술을 한 것이라고는 볼 수 없으므로 법원은 이에 구속되지 아니한다(대법원 1990. 12. 11. 선고 90다7104 판결). 반면 특허침해 소송에서 상대방이 제조하는 제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해 판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결).

구체적 사실 중에서도 간접사실이나 보조사실에 관하여는 자백의 효력(특히 구속력)이 생기지 아니한다(대법원 1992. 11. 24. 선고 92다21135 판결). 예컨대 부동산의 시효취득에서 점유기간의 산정기준이 되는 점유개시의 시기는 간접사실에 불과하므로 이에 대한 자백은 법원이나 당사자를 구속하지 않는다(대법원 1994. 11. 4. 선고 94다37868 판결). 그러나 보조사실의 하나인 문서의 진정성립에 관하여는 자백의 효력이 생기고(대법원 1990. 3. 9. 선고 89다카21781 판결), 문서에 찍힌 인영의 진정성립에 관하여도 자백의 효력이 생긴다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001다5654 판결).

(3) 효 력

재판상 자백은 법원과 당사자 모두를 구속한다. 즉 법원은 증거조사 및 변론 전체의 취지로부터 자백한 사실과 반대되는 심증을 얻었다 하더라도 자백사실에 반하는 사실을 인정할 수 없고, 당사자는 자백을 임의로 취소할 수 없다.

다만 직권탐지주의가 적용되는 경우나(가소 12조 단서), 소송요건 등의 직권조사사항에 대하여는 자백의 효력이 인정되지 않는다(대법원 2002. 5. 14. 선고 2000다42908 판결).

(4) 자백의 취소

일단 자백한 당사자는 임의로 이를 취소할 수 없으며, 다음과 같은 요건에 해당된 경우에 한하여 자백을 취소할 수 있다. 한편 자백의 취소는 반드시 명시적으로 하여야만 하는 것은 아니고 종전의 자백과 배치되는 사실을 주장함으로써 묵시적으로도 할 수 있다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94다22897 판결).

(가) 형사상 처벌을 받을 만한 다른 사람의 행위로 말미암아 자백한 경우(민소 451조 1항 5호의 유추)

(나) 상대방의 동의가 있는 경우

자백취소의 의사표시에 대해 상대방이 동의한 경우에는 자백취소를 인정할 수 있다. 또한 자백을 한 당사자가 종전의 자백과 배치되는 내용의 주장을 하고 이에 대하여 상대방이 이의를 제기함이 없이 그 주장내용을 인정할 때에는 종전의 자백은 취소되고 새로운 자백이 성립된 것으로 보아야 한다(대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카20548 판결). 그러나 자백의 취소에 대하여 상대방이 아무런 이의를 제기하고 있지 않다는 것만으로는 그 취소에 동의하였다고 볼 수 없다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94다22897 판결).

(다) 자백이 진실에 어긋나고 착오로 말미암은 것임을 증명한 경우(민소 288조 단서)

자백이 진실에 반한다는 사실에 대한 증명은 그 반대되는 사실을 직접증거에 의하여 증명함으로써 가능하나 자백사실이 진실에 반함을 추인할 수 있는 간접사실의 증명에 의하여도 가능하고, 자백이 진실에 반한다는 증명이 있다고 하여 그 자백이 착오로 인한 것이라고 추정되는 것은 아니지만 그 자백이 진실과 부합되지 않는 사실임이 증명된 경우라면 변론 전체의 취지에 의하여 그 자백이 착오로 인한 것이라는 점을 인정할 수 있다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2004다13533 판결).

(라) 소송대리인의 자백을 당사자가 곧 취소하거나 경정하는 경우(민소 94조)

문서의 성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 자백이기는 하나 그 구속력이 있으므로 그 취소에 관하여는 간접사실에 관한 자백의 취소와는 달리 주요사실의 자백취소와 동일하게 처리하여야 한다.

나. 자백간주

(1) 의 의

당사자가 변론 또는 변론준비절차에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 보는데(민소 150조 1항, 286조), 이를 '자백간주'라고 한다. 공시송달 이외의 방법으로 기일통지서를 송달받은 당사자가 변론기일 또는 변론준비기일에 출석하지 아니하고 답변서 기타 준비서면을 제출하지 아니한 경우에도 마찬가지이다(150조 3항, 286조). 법원은 피고가 공시송달 이외의 방법으로 소장부분을 송달받고도 30일의 답변서 제출기간 내에 답변서를 제출하지 아니한 경우에는 청구의 원인이 된 사실을 자백한 것으로 보고, 변론 없이 판결할 수 있다(256조, 257조). 다만 당사자가 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 않았더라도 변론 전체의 취지로 보아 다툰 것으로 인정되는 때에는 자백간주가 성립되지 않는데, 여기서 변론 전체의 취지로 보아 다투었다고 볼 것인지는 변론종결 당시까지 당사자가 한 주장 취지와 소송의 경과를 전체적으로 종합해서 판단해야 한다(대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다280781 판결). 제1심에서 피고에 대하여 공시송달로 재판이 진행되어 피고에 대한 청구가 기각되었다고 하여도 피고가 원고의 청구원인을 다툰 것으로 볼 수 없으므로, 원고가 항소한 항소심에서 피고가 공시송달이 아닌 방법으로 송달받고도 다투지 아니한 경우에는 자백간주가 성립한다(대법원 2018. 7. 12. 선고 2015다36167 판결).

자백간주가 인정되는 것은 변론주의에 의한 절차에 한하며, 직권탐지주의가 적용되는 경우(가소 12조 단서) 또는 소송요건 등의 직권조사사항에 대하여는 자백간주가 있을 수 없다.

(2) 효 력

자백간주가 성립하면 법원은 자백과 마찬가지로 이에 구속받는다. 그러나 자백과는 달리 당사자에 대한 구속력이 없으므로, 당사자는 사실심 변론종결 시까지 어느 때라도 상대방의 주장사실을 다투어 이를 번복할 수 있다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87다368 판결).

다. 현저한 사실

‘현저한 사실’이란 법원이 이미 소상하게 알고 있어서 특별한 증거조사를 할 필요가 없을 정도로 객관성이 확보되어 있는 사실을 말한다(민소 288조 본문 후단).

현저한 사실에는 공지의 사실과 직무상 현저한 사실이 있다.

(1) 공지의 사실

일반인에게 널리 알려져 있고 법원도 이를 잘 알고 있는 사실을 말한다. 역사적으로 유명한 사건, 천재지변, 전쟁 등이 이에 해당한다. 일용노동자의 월평균가동일수(대법원 1970. 2. 24. 선고 69다2172 판결), 1962. 6. 16. 법률 제1091호 긴급금융조치법에 의하여 1962. 6. 18.부터 화폐단위로 ‘원’을 사용한다는 것(대법원 1991. 6. 28. 선고 91다9954 판결) 등은 공지의 사실이고, 대금업자가 아닌 사람이 일시적으로 타인에게 금원을 대여하는 경우 이자율이 얼마인가 하는 점은 공지의 사실이 아니다(대법원 1984. 12. 11. 선고 84누 439 판결). 다만 위 69다2172 판결에서는 일반노동자의 월평균 가동일수를 25일로 잡은 것은 공지의 사실에 부합한다고 한 바 있으나, 최근 대법원은 도시 일용근로자의 일일수입을 그 1일 노임에 관한 통계사실에 기초하여 평가하는 경우에는 그 가동일수에 관하여도 법원에 현저한 사실을 포함한 각종 통계자료 등에 나타난 월평균 근로일수와 직종별 근로조건 등 여러 사정들을 감안하고 그 밖의 적절한 자료들을 보태어 합리적인 사실인정을 하여야 한다고 판시하면서, 2014년경 도시 일용근로자의 월 가동일수를 20일을

초과하여 인정하기는 어렵다고 보았다(대법원 2024. 4. 25. 선고 2020다 271650 판결).

(2) 직무상 또는 법원에 현저한 사실

법관이 직무상의 경험으로 알고 있는 사실로서 그 사실의 존재에 관하여 명확한 기억을 하고 있거나 기록 등을 조사하여 곧바로 그 내용을 알 수 있는 사실을 말한다(대법원 1996. 7. 18. 선고 94다20051 전원합의체 판결). 소장의 송달과 같이 해당 기록상 명백한 사실이나, 가압류·가처분의 취소사건에서 그 대상인 가압류·가처분 결정이 발령된 사실, 본안의 제소명령이 발령되어 송달된 사실 등이 이에 해당한다. 피해자의 장래수입상실액을 인정하는 데 이용되는 직종별임금실태조사보고서와 한국직업사전의 존재와 그 기재내용은 법원에 현저한 사실이고(위 94다20051 판결), 통계청이 정기적으로 조사·작성하는 한국인의 생명표에 의한 남녀별 각 연령별 기대여명도 법원에 현저한 사실이다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99다41886 판결). 국제거래 등과 관련된 사건에서 변론종결일 당시 매매기준 환율은 법원에 현저한 사실로 보는 것이 실무이다. 피고와 제3자 사이에 있었던 민사소송의 확정판결의 존재를 넘어서 그 판결의 이유를 구성하는 사실관계들까지 법원에 현저한 사실로 볼 수는 없다(대법원 2019. 8. 9. 선고 2019다222140 판결).

라. 법률상 추정되는 사실

법규화된 경험칙, 즉 추정규정에 의하여 추정되는 사실을 말한다. 추정규정이 있는 경우 증명책임이 있는 당사자는 추정되는 사실을 직접 증명할 수도 있으나 보통은 그보다 증명하기 쉬운 전제사실을 증명함으로써 이를 갈음하게 되는데, 이러한 의미에서 법률상 추정되는 사실은 증명의 필요가 없는 사실이 된다. 법률상의 추정이 되었을 때 이를 깨뜨리기 위하여 그 추정을 다투는 자가 제출하는 증거는 반증이 아니라 본증에 해당한다.

민법 30조(동시사망의 추정), 198조(점유계속의 추정), 844조(남편의 친생자

의 추정), 상법 23조 4항(동일 상호사용의 부정목적 추정), 어음법 20조 2항(일자 기재 없는 배서의 기한전배서 추정), 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 305조 2항(지급정지의 지급불능 추정), 329조 2항(파산선고일에 한 채무자의 법률행위는 파산선고 후의 행위로 추정)이 이에 해당한다.

제2절 증거조사절차

1. 총 설

‘증거조사’란 법관의 심증형성을 위하여 법정의 절차에 따라 인적·물적 증거의 내용을 오관의 작용에 의하여 지각하는 법원의 소송행위이다. 이러한 고유의 증거조사 이외에 그 준비로서 또는 그 실시에 즈음하여 여러 가지 행위가 행하여지는데(예컨대 당사자의 증거신청·증거조사결과원용 등, 법원의 증거 채부 결정·증인출석요구·문서송부촉탁 등), 이와 같이 증거조사와 관련하여 행하여지는 법원 및 당사자의 행위를 합쳐서 ‘증거조사절차’라고 부른다. 증거조사절차는 ① 증거의 신청 → ② 증거의 채부 결정 → ③ 증거조사의 실시 → ④ 증거조사의 결과에 의한 심증형성의 순으로 진행된다.

2. 증거의 신청

가. 의 의

‘증거의 신청’이란 일정한 사실을 증명하기 위하여 일정한 증거방법을 지정하여 법원에 그 조사를 청구하는 소송행위를 말한다. 증명할 사실은 증명 사항이라고도 불리는데, 증거를 신청하는 때에는 증명취지, 즉 증거와 증명할 사실의 관계를 구체적으로 밝혀야 한다(민소규 74조). 예컨대 그 증거방법(증인 갑)이 증명할 사실(매매계약의 성립)에 관하여 어떠한 관계에 있는가(계약의 중개인이거나 계약성립 시에 참여한 사람이라는 사실 등)를 명확히 밝히는

것이다. 증명취지는 구체적으로 밝혀야 하며, 내용이 복잡한 경우에는 서면으로 밝히는 것이 바람직하다. 당사자가 증거를 신청하면서 증명취지를 밝히지 아니할 경우에는 법원이 채부 결정에 앞서 이를 물어 분명히 하여야 한다.

나. 방 법

증거의 신청은 서면 또는 말로 할 수 있다(민소 161조). 증거신청서에는 인지를 붙일 필요가 없으나(인지 10조 단서), 증거조사에 비용을 요하는 경우에는 비용을 예납하여야 한다(민소 116조, 민소규 77조 1항, 19조 1항 3호, 2항).

증거를 신청할 때에는 증거방법을 구체적으로 특정하여야 한다. 증인신문을 신청할 때에는 증인을 지정하여 신청하고, 증인의 이름·주소·연락처·직업, 증인과 당사자의 관계, 증인이 사건에 관여하거나 내용을 알게 된 경위, 증인신문에 필요한 시간 및 증인의 출석을 확보하기 위한 협력방안을 밝히고(민소 308조, 민소규 75조 2항) 이와 더불어 신문할 사항의 개요와 희망하는 증인신문방식과 그 이유를 밝혀야 하며, 나아가 증인이 채택되면 신문방법에 따라 신문사항을 기재한 서면이나 증인진술서 등을 제출하여야 한다(민소규 79조, 80조, 84조). 감정을 신청하는 때에는 감정을 구하는 사항을 적은 서면을 함께 제출하여야 한다(101조 1항). 문서를 제출하여 서증을 신청할 때에는 문서의 제목·작성자 및 작성일을 밝히고 사본을 함께 제출하여야 하고(105조 1항, 2항), 문서제출명령을 신청할 때에는 문서의 표시와 취지 및 문서를 가진 사람, 증명할 사실, 문서를 제출하여야 하는 의무의 원인을 밝혀야 한다(민소 345조). 검증을 신청할 때에는 검증의 목적을 표시하여야 한다(364조).

증거의 신청은 당사자가 법원에 대하여 증거를 조사하여 줄 것을 구하는 것으로서 현실적으로 증거를 제출하는 것과 구분된다. 통상은 증거를 신청하여 채택이 되면 증거조사할 증거방법을 제출하나, 서증의 신청은 소지한

문서를 제출하거나 문서소지자에게 제출을 명할 것을 신청하는 방식 등으로 하며(민소 343조), 법정에서 검증 가능한 검증목적물을 제출하는 경우도 같다(366조 1항).

다. 시 기

(1) 집중증거조사를 위한 증거신청

공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(민소 146조, 적시제출주의). 재판장이 당사자의 의견을 들어 증거를 신청할 기간을 정한 경우 그 기간을 넘긴 때에는 증거를 신청할 수 없도록 하고 있다(147조, 재정기간제도). 다만 증거신청기간을 정할 때에는 증명자료를 준비·제출하는 데 필요한 기간을 충분히 배려하여야 한다(사건관리예규 12. 다. (1)).

사건이 변론준비절차에 부쳐진 경우에는 변론준비절차에서 효율적이고 집중적인 변론 실시를 위하여 필요한 범위 안에서 증거조사를 할 수 있는데, 원칙적으로 증인신문과 당사자신문을 제외한 증거조사를 할 수 있다(민소 281조). 소송당사자는 변론준비기일이 끝날 때까지 변론의 준비에 필요한 증거를 정리하여 제출하여야 하고(282조 4항), 법원은 변론기일에 변론준비절차에서 정리된 결과에 따라서 바로 증거조사를 하여야 한다(287조 3항).

변론준비절차를 거치지 아니한 경우 제1회 변론기일은 쟁점 및 증거를 정리하는 기일로 운영된다. 민사소송법은 집중증거조사제도를 채택하고 있으므로, 가급적 제1회 변론기일에서 필요한 증거를 일괄하여 신청하도록 함으로써 이후의 변론기일에 집중적인 증거조사가 이루어지도록 할 필요가 있다. 특히 증인신문과 당사자신문은 당사자의 주장과 증거를 정리한 뒤 집중적으로 하여야 하고(민소 293조), 이를 위해 증인신문과 당사자신문은 부득이한 사정이 없는 한 일괄하여 신청하여야 한다(민소규 75조 1항).

(2) 소장 제출단계에서 기본적 서증의 제출

원고는 소장을 제출할 때부터 청구원인을 명확히 하고 증명자료를 함께

제출하여야 한다. 특히 피고가 답변방향을 결정하는 데 중요한 단서가 되는 기본적 서증, 예컨대 부동산에 관한 사건에서는 그 등기사항증명서, 친족·상속관계 사건에서는 가족관계기록사항에 관한 증명서, 어음 또는 수표사건에서는 그 어음 또는 수표의 사본, 계약관계 소송에서는 계약서 등은 소장 제출단계에서 그 사본 등을 붙여야 한다(민소규 63조 2항). 또한 원고가 소장에서 서증을 인용한 때에는 그 서증의 등본 또는 사본을 붙여서 제출하여야 한다(민소 254조 4항 참조).

소장을 송달받은 상대방은 답변서를 제출하여야 하는데, 답변서에는 자기의 주장을 증명하기 위한 증거방법과 상대방의 증거방법에 관한 의견을 함께 적어야 하며, 답변사항에 관한 중요한 서증이나 답변서에서 인용한 문서의 사본 등을 붙여야 한다(민소 256조 4항, 274조 2항, 275조).

재판장은 소장을 심사하면서 필요하다고 인정하는 경우에는 원고에게 청구하는 이유에 대응하는 증거방법을 구체적으로 적어 내도록 명할 수 있으며, 원고가 서증에 인용한 서증의 등본 또는 사본을 붙이지 아니한 경우에는 이를 제출하도록 명할 수 있다(민소 254조 4항). 법원사무관등은 소장 접수단계에서 기본적 서증이 첨부되었는지 여부를 심사하고 흠결사항이 있을 경우에는 제출자에게 보정을 권고할 수 있다(민소규 5조 3항). 참여사무관등도 기본적 서증이 첨부되지 아니한 경우에는 자기 명의로 보정을 권고할 수 있다. 방법은 전화나 팩시밀리, 전자우편 등을 적극 활용하고, 이 경우 송달한 보정권고서[전산양식 A1130]의 여백에 “20〇〇. 〇. 〇. 전화통지”와 같은 형식으로 간단히 기재함으로써 송달통지서에 갈음할 수 있다(사건관리예규 4-2. 나., 다.). 전자소송의 경우에는 전자기록뷰어에 공용부전지를 붙여 전화통지 내용을 간단히 기재할 수 있다.

(3) 기일전 증거신청

증거의 신청은 민사소송법 149조, 285조의 제약하에서 변론(준비)기일에서 할 수 있으나, 그 기일 전에도 신청할 수 있다(민소 289조 2항). 이를 기일

전 증거신청 또는 기일의 증거신청이라고 한다. 집중증거조사제도의 효율적인 운영을 위하여 원칙적으로 쟁점정리를 위한 기일 전에 증인신문 등을 제외한 모든 증거신청과 증거자료의 제출·접수를 마쳐야 한다.

증거조사의 실시를 위하여 후속절차가 필요하거나 기간이 오래 걸리는 증거신청, 예컨대 문서송부촉탁이나 감정 등은 사건 진행의 초기단계에 미리 신청하여야 한다. 그러나 증인신문과 당사자신문은 특별한 사정이 없는 한 서증 등 다른 증거방법의 제출상황과 이에 대한 상대방의 의견 등을 고려하여 신청 여부와 범위를 결정하게 되므로 쟁점정리를 위한 기일이 끝나기 전까지만 신청하면 충분하다.

참여사무관등은 증거조사절차의 효율적인 관리를 위하여 기일전 증거의 신청 및 조사에 관한 상황을 일목요연하게 정리하여야 한다. 따라서 기일전 증거신청이 있는 때에는 그 신청·채부·실시(발송 및 결과도착)에 관한 사항을 그 단계마다 곧바로 증인등목록에 적어야 하며, 이와 함께 수시로 점검하여야 할 사항 등은 사건진행카드[전산양식 A1175]의 '증거관계'란에도 적을 수 있다. 전자소송에서는 E-form 양식에 빈칸을 채우는 방식으로 증거신청서를 제출하면 서증은 서증등목록에, 증인신청 등은 증인등목록에 그 문건이 자동으로 입력되어 저장된다.

라. 상대방의 의견진술

증거신청이 있으면 법원은 상대방에게 이에 대한 의견을 진술할 기회를 부여함이 상당하다(민소 274조 1항 5호, 283조 1항 참조). 서증의 사본은 준비서면 등에 첨부·제출되어 상대방에게 송부되는데, 당사자나 대리인은 쟁점이 되는 중요한 서증에 대한 의견은 쟁점정리를 위한 기일 전에 준비서면 등을 통하여 미리 밝혀야 한다(274조 2항). 상대방은 시기에 늦은 신청이라든가, 증거방법이 증거가치가 없다든가, 쟁점의 판단에 불필요한 증거라든가 또는 서증이 인정도용에 의하여 위조되었다든가 등의 증거항변을 할 수 있다.

현재 재판사무시스템은 소송관계인이 인터넷을 통하여 상대방이 신청한 증거(증인의 경우에는 이름 포함)와 그 증거 채부의 결과에 관한 정보까지 검색할 수 있는 체제를 갖추고 있다. 따라서 참여사무관등은 증거신청이 있으면 재판사무시스템에 증거신청에 관한 사항을 바로 입력하고, 나아가 당사자의 참여나 참고자료의 제출이 예상되는 증거방법(감정이나 문서송부촉탁 등)에 대하여는 신청서 부분을 팩시밀리, 전자우편 등을 활용하여 바로 상대방에게 송달함으로써 증거신청에 관한 정보를 적시에 제공하여야 한다.

법원은 상대방에게 진술의 기회를 부여하면 되지, 상대방이 실제로 증거신청에 대한 의견을 진술할 필요는 없다(대법원 1989. 3. 14. 선고 88누1844 판결). 의견진술의 기회를 주었음에도 의견제출이 없으면 소송절차에 관한 이의권(민소 151조)이 포기·상실되었다고 보아서 절차위반의 잘못이 치유된다.

마. 철회

증거의 신청은 증거조사가 개시되기 전이라면 언제라도 철회할 수 있다(대법원 1971. 3. 23. 선고 70다3013 판결). 그러나 일단 개시된 뒤에는 증거공통의 원칙에 따라 증거조사의 결과가 상대방에게 유리하게 참작될 수 있으므로, 상대방의 동의가 있어야 철회할 수 있다. 증거조사가 완료된 후에는 증거신청의 목적이 달성되었기 때문에, 상대방의 동의 여부와 상관없이 철회가 허용되지 않는다는 것이 통설이다. 철회는 기일 또는 기일 전에 말 또는 서면으로 할 수 있다.

3. 증거의 채부 결정

가. 증거신청에 대한 결정

(1) 개요

법원은 당사자로부터 증거신청이 있으면 그에 대하여 신속하게 채부의 결정을 하여야 한다. 채부의 결정을 할 때에 고려할 사항으로는 ① 증거신청의

적법성, ② 증거조사의 필요성, ③ 절차운영의 적정성을 들 수 있다. 증거신청의 적법성이란 증거는 민사소송법, 민사소송규칙이 정한 방법에 따라 신청하여야 하고 법률상 증거로서 허용될 수 있는 자격을 갖추어야 한다는 것을 말한다. 증거조사의 필요성이란 당사자가 신청한 증거방법이 증명할 사실과 관련되어 있어야 하고, 증명할 사실이 인정되면 그것이 청구의 당부를 판단하는 데 직·간접적으로 영향을 미칠 수 있어야 한다는 것을 말한다. 절차운영의 적정성이란 증거의 적시제출주의, 소송지연의 방지, 당사자 사이의 실질적 형평과 공정한 재판 등 소송절차의 적정한 운영이라는 관점을 고려하여 증거의 채부를 결정하여야 한다는 것을 말한다.

위와 같이 고려할 사항의 판단방식과 상호관계는 다음과 같다. 증거신청의 적법성에 관하여는 증거신청이 적법한지 여부 그 자체를 판단하는 방식을 취하게 된다. 증거조사의 필요성에 관하여는 증거채부의 단계에서 증거조사의 필요 여부를 미리 정확하게 판단하기는 어렵기 때문에 그 필요성을 강약의 정도로 파악하는 방식을 취하게 된다. 절차운영의 적정성에 관하여는 적시제출주의 등의 절차운영의 원칙을 증거조사의 필요성과 상호 영향하는 과정을 거치게 된다.

증거신청에 대하여 채부의 결정 없이 변론이 종결되었다면 증거목록에 기재하지 아니하였다 하더라도 그 신청을 묵시적으로 기각하였다고 볼 수 있으나(대법원 1992. 9. 25. 선고 92누5096 판결), 당사자가 별도의 증거를 준비할 수 있도록 명시적으로 기각(또는 각하)결정을 하고 고지하는 것이 바람직하다.

증거의 채부 결정은 소송지휘에 관한 재판이므로 언제든지 취소·변경할 수 있으며(민소 222조), 독립한 불복신청이 허용되지 아니한다. 다만 합의사건의 변론준비절차를 담당하는 재판장등이 한 증거의 채부 결정에 대하여는 당사자가 이의를 신청할 수 있고, 이에 대하여 법원은 결정으로 그 이의신청에 대하여 재판하여야 한다(281조 2항, 138조).

(2) 증거신청의 적법성

증거는 민사소송법과 민사소송규칙이 정한 방법에 따라 신청하여야 한다. 그 자세한 설명은 2. 부분 참조. 이러한 방법을 따르지 않은 증거신청이 상당한 기간 내에 적법하게 보정되지 않거나 증거가 법률상 허용될 수 있는 자격을 갖추지 못한 때에는 그 증거를 채택하지 아니하거나 채택결정을 취소한다.

불법검열이나 불법감청에 의하여 취득한 우편물이나 전기통신의 내용, 공개되지 않은 타인간의 대화를 녹음 또는 청취한 내용은 증거로 사용할 수 없으므로(통비 4조, 14조), 이러한 증거를 대상으로 한 증거신청은 채택할 수 없다. 반면 상대방과 주고받은 대화를 비밀리에 녹음한 녹음테이프, 녹음파일이나 그 녹취서는 증거능력이 있으므로, 이를 대상으로 한 증거의 채부는 증거조사의 필요성과 증거수집의 방법과 태양, 법익 침해의 정도 등 절차운영의 적정성을 종합적으로 고려하여 결정한다.

당사자가 비용을 예납하지 아니한 때에는 법원은 그 증거를 조사하지 아니할 수 있다(민소 116조 2항).

(3) 증거조사의 필요성

당사자가 신청한 증거는 증명할 사실을 인정하는 수단이 되고, 증명할 사실은 당사자의 청구를 법적으로 판단하는 전제가 된다. 법원은 당사자가 신청한 증거라도 증명할 사실과 관련성이 없거나 쟁점의 판단에 도움이 되지 아니하는 등 불필요하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다(민소 290조 본문 참조).

증거의 채부는 원칙적으로 법원의 재량에 맡겨져 있지만, 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거는 반드시 채택하여 조사하여야 한다(민소 290조 단서). 다만 유일한 증거라 함은 당사자가 증명책임이 있는 사항에 관한 유일한 증거를 말하므로 그것이 반증일 경우에는 조사하지 아니하여도 무방하다(대법원 1998. 6. 12. 선고 97다38510 판결).

(가) 증명할 사실과의 관련성

당사자가 신청한 증거와 증명할 사실 사이에 관련성이 있다고 함은 해당 증거를 조사하면 증명할 사실이 인정될 수 있음을 말한다. 증거의 신청 당시를 기준으로 해당 증거가 증명할 사실에 부합하는 내용을 담고 있지 않음이 명백하다면 그 증거를 채택하지 않을 수 있다. 그러나 증거를 조사하기도 전에 미리 그 증거의 신빙성이나 증명할 사실의 존부를 평가하고 이를 이유로 증거와 증명할 사실의 관련성을 부정하여서는 아니 된다. 증거를 신청할 때에는 증거와 증명할 사실의 관련성을 구체적으로 밝혀야 하는데(민소규 74조), 그것이 부족하여 최소한의 관련성조차 제대로 확인할 수 없다면 증거신청을 채택하지 아니한다.

당사자가 신청한 증거의 증거력(증거가치)이 별로 없을 것으로 예상된다는 이유만으로 증거조사의 필요성을 부정하거나 증거신청을 기각하여서는 아니 된다. 그러나 증거에 의하여 증명할 사실이 사소한 정황사실에 불과하여 주요사실이나 쟁점의 판단에 영향을 미치기 어렵다는 등의 사유가 있으면 해당 증거를 채택하지 아니할 수 있다.

증명할 사실에 관한 증거방법이 여럿인 경우에는 그중에서 증명할 사실의 존부와 내용을 판단하는 데 가장 적합한 증거를 우선 조사하는 것이 바람직하다. 신청할 증거방법의 선택권은 당사자에게 있으나, 법원은 당사자와 절차협의를 통하여 관련성이 많은 증거를 우선 조사하고, 관련성의 정도가 비슷하다면 일반적인 신용성이 상대적으로 높은 증거를 우선 조사할 수 있도록 협력하여야 한다.

(나) 쟁점 판단을 위한 필요성

증거에 의하여 증명할 사실이 쟁점의 판단에 필요한 경우라야 해당 증거를 채택할 수 있다. 증거에 의하여 증명할 사실이 인정될 수 있다고 하더라도 그 사실이 쟁점의 판단이나 재판의 결론에 영향을 미치지 않는다면 해당 증거를 채택하지 아니할 수 있다.

증명할 사실의 종류와 내용에 따라 쟁점 판단을 위한 필요성의 유무와 그 정도가 달라질 수 있다. 증명할 사실이 주요사실이면 필요성을 쉽게 인정할 수 있다. 증명할 사실이 간접사실인 경우에는 이를 기초로 경험칙에 따라 주요사실을 추단할 수 있어야 필요성이 인정된다. 증명할 사실이 보조사실인 경우에는 기존 증거의 증명력에 영향을 미칠 뿐만 아니라 쟁점 판단에도 영향을 미칠 수 있어야 필요성이 인정된다.

선행하는 증거조사의 결과에 따라 부동적(浮動的)이나마 일정한 심증이 형성되기 마련이므로, 이러한 상태도 쟁점 판단을 위한 필요성을 인정하는 데 영향을 미칠 수밖에 없다. 그러나 당사자가 신청한 증거를 조사하더라도 기존 심증에 변화가 없을 것으로 예상된다는 이유만으로 새로운 증거조사의 필요성을 부정하거나 증거신청을 기각하여서는 아니 된다. 예를 들어, 요증 사실이 존재한다는 적극적 심증이 있을 경우에는 그 심증의 강약에 상관없이 반증의 조사 필요성을 인정함이 상당하고, 요증사실이 존재하지 아니한다는 소극적 심증이 있을 경우에는 그 심증의 강약에 상관없이 본증의 기회를 부여함이 상당한 반면 반증의 조사 필요성은 별로 없게 된다. 종래 재판부의 심증이 형성되기 전의 단계에서는 폭넓게 증거신청을 채택하다가도 적극적 또는 소극적 심증이 형성된 이후에는 그에 대한 반증 또는 본증에 해당하는 증거신청을 기각하기도 하였으나 이러한 실무는 지양하여야 한다.

선행하는 증거조사의 결과를 반영하여 증거조사의 필요성이 없다는 이유로 증거신청을 채택하지 아니하면 결과적으로 그때까지 형성된 법원의 심증을 암시하는 결과가 될 수 있음을 유의할 필요가 있다. 사안의 성질, 소송의 경과, 당사자의 태도 등에서 나타난 심증교류의 필요 여부를 감안하여 탄력적으로 증거의 채부를 판단함이 바람직하다.

(4) 절차운영의 적정성

증거신청의 적법성과 증거조사의 필요성을 모두 갖추고 있는 경우라도, 전체적인 소송절차의 관점에서 적시제출주의, 소송지연의 방지, 보호해야 하

거나 대립되는 가치의 존중, 증거신청의 남용 방지 등을 위하여 일정한 한도에서 증거신청이 채택되지 않을 수 있다. 반대로 증거조사의 필요성이 다소 미약하더라도 당사자 사이의 실질적 형평과 공정한 재판의 구현, 무익한 상소의 예방, 예단에 의한 증거평가의 방지 등을 위하여 탄력적으로 증거를 채택하여야 할 경우도 있다.

증거신청이 정당한 사유 없이 재정기간을 넘겼거나 고의 또는 중대한 과실로 시기에 뒤늦게 제출되어 소송의 완결을 지연시키는 경우 등에는 그 신청을 각하할 수 있다(민소 147조, 149조, 285조). 정당한 사유의 부존재, 고의 또는 중대한 과실 등의 귀책사유가 존재하는지 여부는 객관적으로 증거신청 자체가 얼마나 늦었는지 그리고 주관적으로 이를 합리화할 수 있는 사유가 무엇인지를 종합적으로 고려하여 판단한다. 예를 들어 소송대리인이 새로 선임되거나 교체되었다는 사정은 주관적 합리화 사유로 인정하기 어려울 것이나, 새로 선임된 소송대리인이 증거조사의 필요성이 큰 증거를 신청하면서 이를 미리 제출하지 못한 사유(당사자 본인의 전문지식 부족, 종전 소송대리인의 판단 착오 등)를 밝히는 경우에는 그 사유를 객관적 절차지연의 정도와 비교衡量하여 귀책사유의 존부를 판단할 수 있다.

또한 증거조사를 할 수 있을지, 언제 할 수 있을지 알 수 없는 경우(민소 291조)에도 절차운영의 적정성을 고려하여 그 증거를 조사하지 아니할 수 있다.

증거조사를 통해 다른 법익을 침해할 우려가 현저한 때에는 실체적 진실 발견의 이익과 침해의 우려가 있는 다른 법익 보호의 이익을 비교衡量한 결과에 따라 증거가 채택되지 않을 수 있다. 주로 증인신문, 금융거래정보의 제공명령이나 건강보험 관련 자료의 사실조치 등에서 문제 되는 사항인데, 증거신청의 남용 우려 정도, 대체적 증명방법의 존부, 증거조사 범위의 광협(廣狹) 및 순차적 증거조사의 요부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

(5) 모색적 증거신청의 허용 여부와 한계

증거조사를 통해 새로운 주장사항을 만들어 내려는 의도에서 신청하는 이른바 ‘모색적 증거신청’은 증거와 증명할 사실의 관계를 제대로 밝히지 않은 것으로서 원칙적으로 적법한 방법에 따른 증거신청으로 볼 수 없다. 다만 모색적 증거신청이라고 하더라도 증거의 구조적 편재 해소, 공정한 재판의 실현 등 적절한 절차운영의 측면에서 예외적으로 허용될 수 있는 경우가 있다.

모색적 증거신청이 적법한 것으로서 허용되려면, 증명취지를 구체적으로 명시하지 않은 채 증거신청을 하게 된 구체적인 사유(예를 들어 상대방의 배타적 증거지배, 증거에 대한 접근 곤란, 법령상의 제한 등)를 밝혀야 하고, 해당 증거방법으로 증거조사의 필요성을 추론하는 것이 합리적이라는 사정이 있어야 하며, 이에 더하여 대체적 증명수단이 존재하지 않는다거나 그러한 방법의 증거신청에 대하여 신청인에게 책임을 묻기 어렵다는 사정이 인정되어야 한다.

위와 같은 사정이 모두 인정되더라도 상대방 또는 제3자의 명예나 프라이버시 등을 과도하게 침해할 우려가 있는 경우, 소송상 필요성에 비하여 상대방 또는 제3자를 심리적 고통이나 재산적 피해로부터 보호할 필요성이 더 큰 경우, 해당 소송에서 필요한 사실의 증명 이외의 다른 목적으로 증거조사를 신청하는 경우에 해당한다고 인정되는 때에는 모색적 증거신청을 허용하지 아니함이 바람직하다. 다만 이 경우에도 법원은 신청인에게 합리적 추론을 바탕으로 증거조사의 필요성이 크다고 인정되는 최소한도의 범위를 특정하도록 권유할 수 있고 그에 따라 침해의 정도가 적절한 범위 내로 낮아진다면 그 범위로 한정하여 증거신청을 채택할 수도 있다.

(6) 증거 채부의 구체적 방식

가) 기일 전 증거신청의 경우

증거의 신청과 이에 대한 채부의 결정은 쟁점정리를 위한 기일 전에도 할 수 있다(민소 289조 2항). 변론준비절차에서 변론준비기일 전에 당사자가 증

거신청을 한 경우 변론준비절차를 담당하는 재판장등은 변론의 준비를 위하여 필요하다고 인정하면 모든 증거신청에 대하여 채부의 결정을 할 수 있다(281조 1항). 변론준비기일 전 증거신청에 대한 채부의 결정방식은 별도의 증거결정서(채택하는 경우의 [전산양식 A1872], 기각하는 경우의 [전산양식 A1878])를 작성하는 방식도 가능하나, 보통은 전자기록사건에서 전자결재로 채부의 결정을 입력하는 방식으로 하고 있다(민전예규 73조 3항). 종이기록의 경우에는 증거신청서 표지의 적당한 부분에 재판장이 채부를 표시하여 날인하는 방식으로 충분하며, 이 경우 고무인 등으로 정형화된 증거결정 방식[전산양식 A1871]을 만들어 사용하는 방식이 효과적이다[사건관리예규 12. 나. (3)].

[전산양식 A1871] 증거결정 방식

채	부
결정: 20○○. ○. ○.	
기일: 20○○. ○. ○. :	

- ※ 고무인을 만들어 증거신청서 표지 오른쪽 상단에 찍는다.
- ※ 기일란에는 지정된 검증기일 등을 적는다.

[전산양식 A1872] 법원의 증거조사결정(채)

		○ ○ 법 원	
		결 정	
사 건	20○○가단○○	손해배상(자)	
원 고			
피 고			
		주 문	
원(피)고의 기일의 증거조사신청을(를) 채택한다.			
증거조사의 내용은 다음과 같다.			
증거방법:			
일 시:			
장 소:			
		20○○. ○. ○.	
		판 사 ㉠	

[전산양식 A1878] 시기에 늦은 공격방법 각하

		○ ○ 법 원	
		결 정	
사 건	20○○가단○○	손해배상(자)	
원 고			
피 고			
		주 문	
원(피)고의 20○○. ○. ○. 자 기일의 (감정신청)을(를) 각하(기각)한다.			
		이 유	
원(피)고의 위 증거신청은 시기에 늦은 공격방법이므로 민사소송법 제149조 제1항에 의하여 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 결정한다.			
		20○○. ○. ○.	
		판 사 ㉠	

기일 전 증거신청에 대한 채부 결정은 양쪽 당사자에게 바로 고지하는 것이 원칙이다. 고지는 증거결정서나 기일의 증거조사 실시통지서[전산양식 A1873] 또는 채부의 날인이 된 신청서 표지를 팩시밀리로 송달하거나, 전화나 전자우편을 이용하여 고지한 후, 그 사실을 신청서 표면이나 그 밖에 적당한 곳에 표시하는 방식으로 할 수 있다[사건관리예규 12. 나. (4)]. 당사자의 참여나 참고자료의 제출이 예상되지 않는 증거방법이 채택된 때에는 실시한 증거조사결과가 도착한 때에 그 결과를 통지함으로써 채택결정의 고지를 갈음할 수 있다.

전자소송에서 증거신청 문건에 대하여 채택을 뜻하는 ‘채’ 결재 또는 불채택을 뜻하는 ‘부’ 결재가 이루어지면, 별도의 고지·통지 조치를 취하지 않아도 곧바로 당사자는 전자기록뷰어에서 그 채부 표시를 볼 수 있으므로, 실무상으로는 채부 결정을 한 때 바로 고지하지는 않고 변론기일에서 한꺼번에 고지하는 방식을 취하고 있다.

참여사무관등은 증거신청의 채부가 결정되면, 재판사무시스템에 그에 관한 사항을 바로 입력하여 증거채택에 관한 정보를 적시에 제공하여야 한다.

(나) 기일에서 증거신청을 한 경우

당사자가 변론준비기일에서 증거신청을 한 경우에는 변론준비절차를 담당하는 재판장등이 변론의 준비를 위하여 필요하다고 인정하면 채부 결정을 하고(민소 281조 1항), 변론기일에서 증거신청을 한 경우에는 재판장이 합의 부원과의 합의를 거쳐 채부 결정을 한다. 결정은 양쪽 당사자에게 상당한 방법으로 고지하여야 하지만(221조 1항), 변론준비기일 또는 변론기일에서는 당사자가 출석하지 아니하여도 결정의 고지가 가능하므로(224조 1항, 207조 2항) 따로 송달 등의 방법으로 고지할 필요가 없다.

나. 직권증거조사결정

변론주의를 근간으로 하는 통상의 민사소송에서, 직권에 의한 증거조사는

당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나 그 밖에 필요하다고 인정한 때에만 보충적으로 할 수 있다(민소 292조). 예컨대 불법행위로 인하여 손해가 발생한 사실이 인정되는 경우 법원은 손해액에 관한 당사자의 주장과 증거가 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 증거를 촉구하여야 하고 경우에 따라서는 직권으로라도 손해액을 심리 판단하여야 한다(대법원 1987. 12. 22. 선고 85다카2453 판결 등). 다만 소액사건에서만은 필요하다고 인정할 때에 직권으로 증거조사를 할 수 있는데, 이 경우 법원은 직권증거조사의 결과에 관하여 당사자의 의견을 들어야 한다(소액 10조 1항).

직권증거조사결정의 방식은 증거신청에 대한 결정의 경우와 대체로 같다(직권에 의한 서증 채택은 거의 없으며 대개 당사자 중 어느 한쪽이 제출하는 형식으로 정리하는 것이 보통이다). 기일 외에서 직권증거조사결정을 하는 경우에는 별도의 결정서를 작성하여야 하는데, 결정 주문은 “직권으로 증인 ○○○를 신문한다(직권으로 …를 행한다). 증인신문기일은(… 기일은) 20○○. ○. ○. 14:00로 정한다.”의 형식으로 한다. 이 경우의 기일지정사실은 재판서에 표시되었으므로 기록표지 다음 면에는 다시 기재할 필요가 없다.

다. 증거조사비용의 예납과 국고대납절차 등

(1) 비용의 예납

법원이 증거조사의 결정을 한 때에는 바로 그 비용을 부담할 당사자에게 필요한 비용을 미리 내게 하여야 한다(민소 116조 1항, 민소규 77조 1항). 비용을 부담할 당사자는 해당 증거조사를 신청한 당사자인 경우가 보통이나, 직권에 의한 증거조사의 경우에는 그 증거조사로 이익을 받을 당사자가 그 비용을 부담하되, 어느 당사자가 이익을 받을지 분명하지 아니한 때에는 원고가 이를 부담하여야 한다(민소규 19조 1항 3호 단서). 당사자가 비용을 미리 내지 아니하는 때에는 법원은 그 증거조사를 아니할 수 있다(민소 116조 2항). 증거조사를 신청한 사람은 명령이 있기 전에도 필요한 비용을 미리 낼 수

있다(민소규 77조 2항).

자세한 예납절차에 관하여는 제13장(소송비용) 참조.

(2) 국고대납절차 등

앞에서 본 바와 같이 당사자가 예납명령에 불응한 때에는 법원은 증거조사를 하지 아니할 수 있으나, 이에 대하여는 다음 두 가지 예외가 있다.

첫째, 예납의무자가 그 비용을 예납하지 아니하여(부족액을 추가로 예납하지 아니하는 경우를 포함한다) 소송절차의 진행 또는 종료 후의 사무처리가 현저히 곤란한 때에 법원이 그 소송비용을 국고에서 대납받아 지출할 수 있다(민소규 20조). 비용의 국고대납절차에 관하여는 제13장(소송비용) 참조.

둘째, 민사소송법 128조 이하의 규정에 의하여 재판비용의 납입유예에 관한 소송구조결정을 받은 당사자에 대하여는 소송비용 중 재판비용의 지급이 유예되므로 그 예납을 명할 수 없다. 소송구조결정의 절차에 관하여는 제15장(소송구조) 참조.

4. 증거조사의 실시

가. 진행단계별 증거조사

(1) 기일 전 증거조사

재판장과 참여사무관은 소장·답변서·준비서면 등을 검토하면서 필요한 서증이 빠짐없이 제출되었는지 여부를 확인하고, 누락된 경우에는 석명준비명령 또는 보정권고 등을 통하여 당사자에게 첫 변론기일 또는 변론준비기일 이전까지 서증을 제출하도록 촉구하여야 한다. 당사자가 서증을 제출한다는 것은 스스로 소지하고 있는 문서는 그 사본을 미리 제출하여 상대방에게 검토할 기회를 부여한 후 기일에 그 원본을 현실적으로 제출한다는 의미이고(민소규 108조 참조), 소지하고 있지 않는 문서는 적시에 문서제출명령·문서송부촉탁 또는 법정 외에서의 증거조사 등을 신청함으로써 필요한 문서가 기일 전에 법원에 현출되어 상대방과 법원이 그 내용을 검토할 수 있도록

록 하여야 한다는 의미이다. 따라서 법원은 이러한 절차가 적시에 이루어지도록 석명권 등을 행사하여 증거신청을 촉구하여야 한다(73조, 30조).

문서송부촉탁·현장검증·감정·사실조회 등의 증거방법에 대한 조사도 원칙적으로 기일 전에 실시함으로써, 법원이 그 내용을 검토할 수 있어야 한다. 따라서 감정 등이 필요한 전형적인 사건에서 그 신청이 적시에 이루어지지 아니하는 때에는 재판장 또는 그 위임을 받은 참여사무관등이 증거신청을 촉구하여야 한다(사건관리예규 12. 나. (1)). 감정 등의 신청은 기일 전에 이루어지고 특별한 사정이 없는 한 신청 직후 채부를 결정하여 시행하는 것이 원칙이다.

(2) 기일에서의 증거조사

법원은 기일에 원칙적으로 증인신문 등을 제외한 증거방법에 대한 조사를 완료하여야 한다. 기일에는 제출된 증거(사실조회회보·검증·감정 등)의 결과를 제시하여 당사자에게 의견진술의 기회를 부여하고, 신청된 서증에 대한 채부를 결정하고 채택된 서증에 대하여 상대방이 인부를 실시하는 방법으로 증거조사가 시행된다(사건관리예규 13.). 제출된 서증에 대한 채부 결정은 미리 검토해 두었다가 기일에 그 결과를 고지하는 방식으로 행한다.

기일에는 신청된 증인에 대한 채부를 일괄하여 결정·고지한다. 또한 이때 개별 증인별로 그 증인의 증명취지, 증인과 당사자와의 관계 등을 고려하여, ① 증인진술서 제출방식, ② 증인신문사항 제출방식, ③ 서면에 의한 증언방식 중 하나를 선택하여 이를 양쪽 당사자에게 고지한다.

(3) 집중증거조사기일에서의 증거조사

쟁점정리를 위한 기일을 마친 후에는 법원은 별도로 변론기일(증거조사기일)을 지정하고, 증인 및 당사자신문을 집중하여 실시하게 된다(민소 293조). 이와 같이 주로 증인신문을 위하여 운영되는 변론기일을 집중증거조사기일이라고 한다. 법원은 원칙적으로 1회 변론기일로 증인신문을 마칠 수 있도록 기일을 운영하여야 하고(287조 1항, 민소규 72조), 증인신문 등은 쟁점정리를

위한 기일에서 확정된 쟁점사항에 집중하여 실시되어야 한다(민소 293조).

(4) 집중적 증거조사의 연쇄적 성격

집중적 증거조사는 쟁점정리를 위한 기일전 증거조사 → 쟁점정리를 위한 기일에서의 증거조사 → 집중증거조시기일에서의 증거조사의 각 단계별로 적시에 제대로 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 즉 선행 단계에서의 증거조사가 적시에 제대로 이루어지지 않으면 후행 단계에서의 증거조사가 지연되거나 허술하게 되어, 불필요한 기일의 연기·속행을 초래하게 되고 결과적으로 심리기간이 지연된다는 점에 유의할 필요가 있다.

나. 변론준비절차에서의 증거조사

증거조사는 수소법원이 하는 것이 원칙이나, 변론준비절차에서는 변론준비절차를 진행하는 재판장등이 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 범위 안에서 증거조사를 할 수 있고, 다만 증인신문과 당사자신문은 민사소송법 313조에 해당하는 경우에만 할 수 있다(민소 281조 3항). 이 경우 재판장등은 민사소송법에서 정한 법원과 재판장의 직무를 행한다(4항). 이와 같이 변론준비절차에서 실시한 증거조사는 직접주의의 요청상 조사결과를 법원에 현출하여야 하는데, 당사자는 변론준비기일을 마친 뒤의 변론기일에서 증거조사의 결과를 진술하여야 한다(287조 2항).

법원은 필요하다고 인정하는 경우에는 변론준비기일 전에도 증거조사를 할 수 있는데(민소 281조 3항), 조사의 촉탁, 감정의 촉탁, 감정인에 의한 감정, 법원 밖 서증의 조사, 검증의 실시 등은 변론준비기일 전에 실시하는 것이 상당하다.

증거조사는 법원 안에서 행하는 것이 원칙이나(법조 56조 참조), 증거조사를 실시하는 법원은 현장검증, 증인의 임상(臨床)신문, 제3자 소지 문서의 서증조사 등 필요하다고 인정할 때에는 법원 밖에서도 증거조사를 할 수 있는데(민소 297조 1항 전단, 민소규 112조), 이 경우에는 증거조사기일이 변론(준

비)기일과 분리되며, 공개할 필요는 없다(대법원 1971. 6. 30. 선고 71다1027 판결).

위와 같은 법원 밖 증거조사의 경우에는 합의부원(수명법관)에게 그 실시를 명하거나 다른 지방법원의 판사(수탁판사)에게 그 실시를 촉탁할 수 있다(민소 297조 1항 후단). 다만 법원 밖 증인신문을 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 실시하게 하기 위하여는 민사소송법 313조가 요구하는 별도 요건이 구비되어야 한다.

외국에서 시행할 증거조사는 그 나라에 주재하는 대한민국 대사·공사·영사 또는 그 나라의 관할 공공기관에 촉탁하여 시행하는데(민소 296조 1항), 그 구체적인 절차에 관하여는 제40장(국제민사사법공조) 참조.

다. 당사자의 참여

증거조사기일도 기일의 일종인 이상 긴급한 경우를 제외하고는 미리 그 일시·장소를 당사자에게 통지하여야 한다(민소 167조 1항, 381조). 기일통지의 방식은 앞서 변론(준비)기일의 통지에 관하여 설명한 바와 같다.

증거조사기일이 변론(준비)기일 등과 일치할 때에는 변론(준비)기일 등에 대한 통지서(또는 출석요구서)를 송달함으로써 족하며 따로 증거조사기일에 대한 통지서 등을 송달할 필요가 없으나, 독립된 증거조사기일일 때에는 증거조사기일통지서[전산양식 A1607] 등을 따로 송달하여야 한다.

증거조사기일의 통지를 한 이상 그 기일에 당사자의 전부 또는 일부가 불출석하였다 하더라도 증거조사를 실시할 수 있다(민소 295조). 따라서 증인신문기일에 증인이 출석하였다면 가령 그 증인을 신청한 당사자가 불출석하였다 하더라도 법원이 증인신문을 마칠 수 있다. 다만 증거조사기일과 변론(준비)기일이 겹친 경우에 당사자 쌍방의 기일해태(불출석 또는 변론하지 않음)에 따른 이른바 쌍불)가 있는 때에는 그 증거조사를 할 수 없다고 해석된다. 반면 독립된 증거조사기일일 경우에는 당사자가 모두 불출석하였다 하더라도 증

거조사를 실시할 수 있다.

법원은 증거조사의 결과에 대하여 당사자에게 변론의 기회를 부여하여야 하고, 법원이 직권으로 증거조사한 결과에 대하여는 당사자의 의견을 들어야 한다.

라. 증거조사조서

증거조사의 절차 및 결과는 변론기일 또는 변론준비기일에 행한 경우에는 변론조서(민소 154조 2호, 3호) 또는 변론준비기일조서(283조)에, 그렇지 않은 경우에는 증거조사기일의 조서에 기재하여야 한다(160조). 구체적으로, 증거의 신청, 채부의 재판, 증거조사기일의 지정, 증거신청에 대한 상대방의 진술, 증거조사의 결과 등 증거조사절차에 관한 사항 등이 기재된다.

수소법원이 법정에서 행한 증거조사결과는 당연히 재판의 기초로 할 수 있으나, ① 수명법관·수탁판사에 의한 증거조사, ② 외국에서 한 증거조사, ③ 수소법원이 법원 밖에서 한 증거조사의 결과는, 당연히 재판의 기초가 되는 것이 아니고 변론에서 제시(현출)하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 부여하여야만 재판의 기초로 될 수 있다. 이 경우의 변론조서의 기재방식은 제23장(조서의 작성 및 변론의 녹음 등) 참조.

소액사건에서 증인신문조서·감정인신문조서·당사자신문조서·검증조서 등의 작성은 당사자의 이의가 있는 경우를 제외하고는 판사의 허가를 얻어 생략할 수 있다(소액 11조 1항).

5. 증거목록의 작성

가. 개 설

(1) 서증목록과 증인등목록

증거의 신청과 채부 결정, 증거조사기일의 지정, 증거신청에 대한 상대방의 진술과 증거조사의 경과 등은 변론조서나 변론준비기일조서 또는 증거조

사조서 자체에 기재하는 것이 아니라 별도의 서증목록[전산양식 A1876]과 증인등목록[전산양식 A1877]에 기재하여야 하는데, 서증목록에는 서증에 관한 사항 중 서증의 현실적인 제출에 관련되는 사항을, 증인등목록에는 그 밖의 모든 증거(증인신문·검증·감정·사실조회 등)에 관련되는 사항과 서증에 대한 문서제출명령·문서송부촉탁·법원 밖 서증조사에 관련되는 사항을 기재한다.

전자기록사건에서는 ‘서증등목록’이라 부른다. 이는 전자문서에 대한 증거조사에 관한 특례 규정(민전 13조 1항)을 고려한 명칭이다.

(2) 증거목록과 기본조서

증거목록은 형태상으로는 기본조서와 분리되어 있으나 내용상으로는 기본조서의 일부를 이루는 것이므로 증거목록에 어떤 사항을 기재할 때에는 반드시 기본조서의 기일 차수를 기재하고(변론기일 또는 변론준비기일 외의 사항일 때는 “기일외”라고 기재함), 이에 대응하는 기본조서에는 당사자의 출석란에 증인 등의 출석 여부의 기재와 변론의 요지란 마지막 부분의 바로 위에 “별지 조서와 같이 증인(당사자 본인, 감정인)신문”이라고 기재하고, 관계 당사자와 증거목록의 종별을 명시하여 “증거관계 별지와 같음(원고 서증·증인등, 피고 증인등)” 등과 같이 기재하여야 한다(조서예규 2조). 한편 증거조사결과는 변론조서 등의 일부인 증인신문조서·당사자신문조서·감정인신문조서·검증조서 등으로 작성한다.

(3) 증거목록의 기본적인 작성 및 편철

증거목록의 작성에 관하여는 ‘민사 등 증거목록에 관한 예규’가 제정되어 있는바, 서증목록과 증인등목록에 공통되는 사항은 다음과 같다.

(가) 용 지

증거목록은 원고·피고·독립당사자참가인 및 직권분마다 별개의 용지를 사용한다. 보조참가인은 당사자가 아니므로 피참가인의 증거목록을 그대로 사용하고 ‘비고’란에 “보조참가인 신청” 또는 “보조참가인 제출”이라고 기재한

다. 일방 당사자가 여러 사람인 경우에는 원칙적으로 별개의 용지를 사용하지 아니하되 ‘비고’란에 “피고 ○○○ 신청”, “피고 ○○○ 제출” 등과 같이 증거신청인의 이름을 기재한다(민사증거목록예규 2조 1항, 14조 3호).

(나) 편 철

증거목록은 기록목록 다음에 철하되, 원고 서증목록, 원고 증인등목록, 피고 서증목록, 피고 증인등목록, 독립당사자참가인 서증목록, 독립당사자참가인 증인등목록, 직권분 증인등목록 순으로 편철한다. 증거목록 상호 간에는 간인하지 아니한다(민사증거목록예규 3조).

(다) 변론의 분리·병합이 있는 경우

변론을 분리하여 분리사건에 관한 기록을 새로 조제한 때에는 기본사건의 증거목록은 그대로 계속 기재하여 나가며, 분리한 사건에도 기록등본으로서 편철된 증거목록에 이후의 사항을 계속 기재하여 나간다(민사증거목록예규 4조 1항). 변론을 병합한 때에는 병합된 사건의 증거목록은 그대로 두고, 기본사건의 증거목록에 병합 이후의 사항을 기재한다(2항).

(라) 상소·재심의 경우

상소심의 증거목록은 제1심의 증거목록 용지를 계속 사용하되, 제1심 증거목록의 기재가 끝난 다음 줄에 상소법원명을 붉은 색으로 기재하고 그 오른쪽에 사건번호를 부기한다. 이송사건과 환송사건의 경우에도 이에 준하여 처리하며, 재심사건은 재심기록에 증거목록을 새로 편철한다(민사증거목록예규 5조 1항, 2항).

편철된 증거목록의 용지가 부족하여 상소심에서 용지를 가철할 경우에는 마지막 용지 장수를 모변호로 하고 그에 자번호를 부기하여 장수 표시를 한다. 예컨대 마지막 용지 장수가 5번이면 “5-1, 5-2, 5-3” 식으로 기재한다(민사증거목록예규 5조 3항).

(4) 전자기록사건의 증거목록 작성

전자소송에서 증거신청을 전자제출하는 것은 빈칸 채우기 방식(E-form 양

식)으로 제출하거나 또는 미리 작성된 전자문서를 첨부해서 제출하거나 또는 종이문서로 작성된 것을 스캔 등으로써 전자문서로 변환하여 첨부해 제출하는 방법으로 할 수 있는데, 각 경우의 증거목록 작성은 다음과 같이 한다.

당사자나 대리인이 전자소송포털을 통해 빈칸 채우기 방식(E-form 양식)으로 증거신청을 한다면, 서증의 경우 서증등목록의 해당 항목이, 증인신청 등의 경우 증인등목록의 해당 항목이 자동으로 작성되고 ‘접수’ 상태로 있게 되며, 그 신청 문건인 전자문서와의 연결도 자동으로 된다.

종이서류로 증거신청서를 제출하거나 또는 전자소송포털에서 E-form 방식이 아닌 파일 첨부 방식으로 증거신청을 제출한 경우에는, 법원사무관등이 번호·명칭 등을 직접 입력하거나 입력된 것을 수정하여 증거목록의 해당 항목을 작성하고, 여기에 그 신청 문건인 전자문서를 연결한다.

나. 증인등목록의 기재방법

이하에서는 증인등목록만을 대상으로 구체적인 작성방법을 설명한다. 서증목록에 관하여는 서증의 증거조사를 설명하는 제27장(서증) 참조.

(1) 사건표시

증거목록 양식 좌측 상단에 해당 증거목록이 어느 사건의 증거목록인가를 밝히기 위하여 사건의 표시를 한다. 특정 법원의 사건번호만 기재하면 족하다.

(2) ‘기일 및 장수’란(민사증거목록예규 16조)

‘기일’란은 변론(준비)기일에 증거신청된 경우에는 해당 증거방법이 신청된 변론(준비)기일의 차수를 ‘준비 ○차’ 또는 “○차” 식으로 기재하고, 기일의 증거신청의 경우에는 “기일외”라고 기재하며, 증거보전기록의 경우에는 “증거보전”이라고 기재한다.

‘장수’란에는 해당 증거자료의 실질적 내용이 나타난 부분의 첫 장의 장수를 기재한다. 예컨대 증인신문조서·감정서(감정을 명한 감정인 신문조서가 아님)·검증조서(검증기일조서가 아님)·사실조회 회보서(사실조회 발송공문이 아

님)·법원 밖 서증조사조서·문서제출명령 등의 각 첫 장의 장수이다.

다만 문서송부촉탁의 경우에는 송부되어 온 문서 자체는 서증목록에 따로 표시되므로 송부되어 온 공문의 첫 장의 장수를 기재하고, 수탁판사에 의한 증거조사 및 증거보전의 경우에는 증거조사기록이 본안기록에 첨부되므로 “첨철”이라고 기재하며, 증거조사가 철회·취소·불능 등으로 실시되지 못한 경우에는 공란으로 둔다.

(3) ‘증거방법’란(민사증거목록예규 17조)

(가) 증인

“증인”이라고 기재하고 증인의 성명을 표시한다[예: 증인 ○○○, 재정증인 ○○○]. 기일에 말로 ‘김모’ 또는 ‘○○은행 당좌계 대리’ 등으로 신청하였을 때에는, 우선 연필로 기재하여 두었다가 후에 정확한 증거신청이 있을 때 정확히 기재한다.

(나) 감정

“감정”이라고 기재하고 그 옆에 “(유익비)”, “(시가)”, “(신체)” 등으로 감정 목적을 괄호 안에 표시한다. 감정의 촉탁(민소 341조)도 이에 준하여 “감정촉탁(신체)”이라는 식으로 기재한다.

(다) 법원 밖 서증조사 또는 문서제출명령·문서송부촉탁

이 경우에는 각각 “법원 밖 서증조사”, “문서제출명령”, “문서송부촉탁”이라고 기재하고, 괄호 안에 서증조사 시행장소 또는 문서의 소재지, 문서소지인, 송부촉탁 대상기관 명칭 등을 부기한다.

(라) 사실조회

“사실조회”라고 기재하고, 괄호 안에 조회대상기관의 이름을 부기하며, 사실조회가 여러 번 시행되었을 때에는 제목 등 간략한 내용까지 부기하여 특정하기 쉽도록 하여야 한다.

(마) 검증

“검증”이라고 기재하고 괄호 안에 “문서, 현장” 등으로 그 목적을 표시한다.

(배) 당사자신문

당사자가 한 사람일 경우에는 “원고본인”, “피고본인”이라고 표시한다. 수인인 한쪽 당사자 중 1인일 경우에는 “원고본인 ○○○” 등으로 기재한다. 법정대리인이나 법인의 대표자인 경우에는 “원고 법정대리인 ○○○”, “피고 대표이사 ○○○”와 같이 그 이름을 기재한다.

(사) 자기디스크등 출력문서

컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 유사한 정보저장매체(자기디스크등)에 기억된 문자정보를 출력한 문서(출력문서)로 제출하는 경우(민소규 120조 1항) “출력문서조사(자기디스크등)”라고 기재한다.

(4) ‘증거결정’란(민사증거목록예규 18조)

‘기일’란은 변론(준비)기일에서 채부 결정을 한 경우에는 변론(준비)기일의 차수를 기재하고, 기일외에서 채부 결정을 한 경우에는 “기일외”라고 기재하며, 증거보전의 경우에는 “증거보전”이라고 기재한다.

‘채부’란에는 증거신청을 채택한 경우에는 ‘채’에, 불허한 경우에는 ‘부’에 ○ 표시를 한다. 직권분 증인등목록에는 항상 ‘채’에 ○ 표시를 한다. 신청된 증거에 대하여 그 채부 결정이 유보되었다가 그 후의 기일에 채택되었으면 채택된 기일의 차수만 기재하고, 채부 결정이 없이 종결되었으면(목시적 각 하) ‘채부’란 이하를 공란으로 둔다.

(5) ‘증거조사’란(민사증거목록예규 19조)

‘증거조사’란에는 증거조사의 진행경과와 구체적 실시내역을 기재하는 것을 원칙으로 하며, 증거조사기일이 진행되는 경우와 그렇지 아니하는 경우로 구분하여 기재한다.

(가) 증거조사기일(감정인신문기일 포함)이 진행되는 증거방법에 관하여는 지정·변경·연기·속행된 증거조사기일의 일시 및 지정된 증거조사기일의 실행·변경·연기·속행의 취지를 기재한다.

구체적으로는 지정된 기일을 “20○○. ○. ○.”라고 기재하고 그 기일이 진행

되었으면 기일의 기재 옆에 “(실시)”라고 기재하며, 그 기일이 변경·연기·숙행된 경우에는 기일의 기재 옆에 “(변경)”, “(연기)”, “(숙행)” 등으로 기재한 후 그 아래에 새 기일 또는 다음 기일을 기재한다.

(나) 증거조사기일이 진행되지 않는 증거방법에 관하여는 증거방법에 따라 다음과 같이 기재한다.

- ① 서면증언: 서면증언의 제출기한 및 도착일
- ② 감정(감정촉탁): 감정인의 지정 및 지정일(감정촉탁일), 감정서 도착일
- ③ 문서제출명령: 문서제출명령일, 문서제출일
- ④ 문서송부촉탁: 문서송부촉탁일, 문서도착일
- ⑤ 사실조회: 사실조회일, 사실조회도착일

(다) 증거보전의 경우에는 증거보전절차에서의 증거조사기일의 진행 여부에 따라 위 (가) 및 (나)에 의하여 기재한다.

(6) ‘비고’란(민사증거목록예규 20조)

‘비고’란에는 다음 사항들을 기재한다.

(가) 양쪽 당사자 신청의 취지

같은 증거방법을 원고·피고 양쪽 당사자가 신청하였을 경우에는 원고·피고의 각 증인등목록에 “양쪽 당사자 신청”이라고 기재한다. 예납명령을 함에 편리하다.

(나) 증거조사비용의 예납명령에 관한 사항

변론(준비)기일에서 예납명령이 있었다면 “○차 변론(준비), 비용 ○○원 예납명령”으로, 기일외의 경우라면 “20○○. ○. ○. 비용 ○○원 예납명령”으로 기재한다.

(다) 수탁판사에 의한 증거조사에 관한 사항

수탁판사에 의한 증거조사가 행하여졌을 때에는 “20○○. ○. ○. 촉탁”이라고 기재하고, 수탁판사로부터 송부받았을 때에는 “20○○. ○. ○. 조서 도착”이라고 기재하며, 변론에 상정할 때에는 “○차 변론(준비), 현출”이라고 기

재한다.

(라) 증거신청의 철회에 관한 사항

변론(준비)기일에 철회한 경우에는 “○차 변론(준비), 철회”, 기일외에서 철회한 경우에는 “20○○. ○. ○. 철회”라고 기재한다.

(마) 증거결정의 취소에 관한 사항

비용예납의 불이행 등으로 증거결정을 취소한 때에는, 취소결정이 있었던 변론(준비)기일의 차수를 명시하여 “○차 변론(준비), 취소”라고 기재한다. 채택된 증거에 대하여 증거조사가 실시되지 않은 채로 변론종결된 경우에는 묵시적인 취소결정이 있는 것으로 보아 변론종결기일에 취소된 것으로 기재함이 상당하다.

(바) 증거항변에 관한 사항

증거신청에 대하여 상대방으로부터 증거가치가 없다거나 증거조사절차가 위법하다는 등의 증거항변이 있을 때에는 해당 증거의 ‘비고’란에 “○차 변론(준비), ○○○의 강박에 의한 증거항변” 등으로 간명하게 기재한다.

(사) 증거신청에 관한 상대방의 의견진술에 관한 사항

증인신청의 불채택을 구하기 위한 진술, 증거신청에 대하여 상대방이 증거조사에 부정기간의 장애(민소 291조)가 있다거나 시기에 늦은 증거신청(149조)이라는 진술이 있을 때에는 해당 증거의 ‘비고’란에 “○차 변론(준비), 시기에 늦은 증거신청이라고 진술” 등의 방법으로 기재한다.

(아) 증거보전에 관한 사항

소송계속 전에 실시한 증거보전기록이 수소법원에 송부되었을 때에는 증거보전법원의 이름과 도착일자를 “○○법원, 20○○. ○. ○. 도착”이라고 기재하고, 변론에 상정된 때에는 변론 상정일자를 “○차 변론(준비), 현출” 방식으로 기재한다.

(자) 증인진술서 또는 증인신문사항의 제출기한

증인진술서 또는 증인신문사항의 제출을 명한 경우에 “진술서(신문사항)

(2000. 0. 0.까지)”라고 기재한다.

(차) 서면증언 후 출석증언한 기일 및 취지

서면증언서를 제출하였으나 출석·증언한 때에는 “○차 변론, 출석증언”과 같이 증인이 출석·증언한 기일을 기재한다.

(카) 증인 상호 간 내지 증인과 당사자 본인 간 대질에 관한 사항

“증인○○○와 대질” 또는 “증인○○○와 원고 본인과 각 대질”로 기재한다.

(타) 반대신문권의 포기에 관한 사항

증인신문이 속행되었으나 속행기일에 신문권이 있는 당사자가 신문권을 포기(반대신문권의 포기)한 관계로 그 증인신문을 하지 않기로 한 때에는 “○차 변론, 원고(피고) 신문권 포기, 신문종료선언”이라고 기재한다.

(파) 기타 절차적 특이사항

위에서 열거한 사항 외에 절차적 특이사항을 기재한다. 예컨대 검증목적물에 대하여 부호와 번호를 붙이는 경우에 “검갑 제○호증”으로 기재하고, 문서제출명령 등으로 제출된 문서에 대하여 당사자가 서증으로 제출하지 않겠다고 한 때에는 그 취지를 기재한다.

또한 민사소송법 140조 1항 4호, 5호의 검증·감정·조사촉탁의 석명처분을 한 경우에는 직권분 증인등목록의 ‘비고’란에 “민사소송법 140조에 의한 석명처분”이라고 기재하고, 후에 당사자가 이를 증거로 하거나 직권으로 증거로 할 때에는 “○차 변론(준비) 원고가 증거로 원용”, “○차 변론(준비) 직권에 의하여 증거로 함” 등으로 추가 기재한다.

[증인등목록 기재례]

○ ○ 법 원					
증 인 등 목 록					
20 가					
고 신 청		변론(준비기일)조서의 일부			
기일 및 장 수	증 거 방 법	증 거 결 정		증 거 조 사	비 고
		기 일	채 부		
기일	문서송부촉탁 (의정부지방법원 고양지원)	기일	채 부	2025. 5. 4. 촉탁	1차 준비 청리, 원고가 서증으로 제출
장					
기일	사실조회 (고양세무서)	기일	채 부	2025. 5. 4. 발송 2025. 5. 31. 도착	
장					
기일	감정촉탁 (신체)	기일	채 부	2025. 5. 3. 촉탁 2025. 6. 26. 도착	
장					
기일	견증(현장)	기일	채 부	2025. 7. 14. 14:00(변경) 2025. 8. 9. 14:00(식사)	
장					
기일	감정 (사고원인)	기일	채 부	2025. 7. 21. 감정인 이응동 지정 2025. 8. 9. 14:00(식사) 2025. 8. 23. 감정서제출	
장					
준비 1차	증인 김강동	준비 1차	채 부	2025. 9. 12. 14:00(식사)	신문사향 (2025. 8. 29. 까지)
장					
준비 1차	증인 박병정	준비 1차	채 부	서면증언 (2025. 9. 12. 까지) 2025. 9. 11. 도착	2차 변론, 출석증언
장					
증거보전	증인 강정동	증거보전	채 부	2025. 7. 21. 14:00(식사)	고양지원 2025. 9. 5. 도착 1차 변론, 현출
청청					

제3절 증거보전

1. 의의

증거보전이란 소송계속 전 또는 소송계속 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본안소송에서 사실을 인정하는 데 사용하기 위한 증거조사방법이다. 의료소송과 같이 본안소송에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다려서는 그 증거를 본래의 사용가치대로 사용하는 것이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 판결절차의 부수절차이다(민소 375조).

증거보전은 미리 그 증거를 조사하는 것이기 때문에 증거조사가 되면 당사자 한 쪽의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방 당사자에게 알리는 ‘증거공개기능’도 있으며, 공판전의 증거개시제도(pretrial discovery)가 없는 우리 법제하에서 소송전 증거수집제도로 이용되도록 탄력적으로 운영하는 것이 바람직하다.

2. 요건

(1) 증거보전의 대상이 되는 것은 모든 증거방법이다. 증인신문·감정·서증조사·문서제출명령·문서송부촉탁·검증은 물론 당사자신문도 가능하다.

(2) 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있어야 한다(민소 375조). 이를 보전의 필요성이라고 한다. 증거가 멸실되어 가고 있어 조사가 불가능하게 될 경우는 물론이고 시간의 경과에 따라 조사가 점점 더 어렵게 된다는지 현상이 변경될 염려가 있는 경우, 증거조사의 비용이 현저히 증가하는 경우도 포함된다. 예컨대 증인이나 당사자 본인이 위독하거나 고령으로 여명을 보장하기 어렵거나, 외국에 나가 당분간 귀국을 기대할 수 없는 경우, 공문서 또는 소송기록이나 등기신청서류의 보존기간의

경과로 인한 폐기의 염려가 있는 경우 등이다. 미리 증거보전을 할 필요가 있는지 여부는 그 소송의 계속 중 정규의 증거조사를 해야 할 시기를 기준으로 한다.

다만 증권관련집단소송에서는 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있지 아니한 경우에도 증거보전을 할 수 있다(증집 33조).

(3) 당사자가 증거보전을 신청하여야 한다. 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항, 인지액·편철방법예규). 소송이 계속된 중에는 법원이 직권으로도 증거보전의 결정을 할 수 있으나(민소 379조), 실무상 그런 예는 거의 없다. 다만 소송절차 진행 중에 당사자의 신청으로 증거결정을 하였는데 그 증거조사 시행 전에 소송절차가 중단된 경우 법원이 소송절차 중단에도 불구하고 증거조사를 할 필요가 있다고 인정한 때에는 직권으로 증거보전의 결정을 하여 그 증거조사를 실시할 수 있을 것이다.

(4) 증거보전을 필요로 하는 사유는 신청인이 이를 소명하여야 한다(민소 377조 2항). 보전의 사유가 없으면 신청을 받아들일 수 없지만, 그 증거에 의하여 증명할 사실이 소송에서 쟁점의 판단이나 재판의 결론에 영향을 미치는 중요한 사실인지 여부는 신청의 허부와는 관계가 없다.

3. 절 차

가. 관할법원

(1) 소제기 후

소를 제기한 후에 증거보전신청을 하는 경우의 관할법원은 그 증거를 사용할 심급의 법원이 된다(민소 376조 1항 전문). 제1심법원이 변론을 종결한 때에는 변론재개의 신청과 함께 증거보전신청을 하는 경우가 아니면 제2심법원이 관할법원이 된다. 다만 이에 대하여는 상소를 제기할 때까지나 제1심법원에 소송기록이 있을 때까지 제1심법원이 관할법원이 된다는 견해도 있다.

(2) 소제기 전

신문을 받을 증인·감정인·당사자의 거소, 증거로 할 문서를 가진 사람의 거소 또는 검증하고자 하는 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원이 관할 법원이 되고(민소 376조 1항 후문), 단독판사의 소관이다(법조 32조).

(3) 급박한 경우

급박한 경우에는 소를 제기한 뒤에도 소제기 전에 증거보전신청을 하는 경우의 관할법원에 신청할 수 있다(민소 376조 2항). 이때에는 급박한 사유를 소명하여야 한다.

(4) 이 송

증거보전신청이 관할법원 이외의 법원에 제출되었을 때에는 민사소송법 34조를 유추하여 이송할 수 있고, 또한 같은 법 35조를 유추하여 손해 또는 지연을 피하기 위하여도 이송할 수 있다고 해석된다.

나. 신 청

(1) 증거보전의 신청은 다음 사항을 밝혀, 서면으로 하여야 한다(민소 377조, 민소규 124조 1항).

① 상대방의 표시

그러나 상대방을 지정할 수 없는 경우(예컨대 도주 교통사고의 경우)에도 증거보전의 신청을 할 수 있는데, 이 경우에는 법원은 상대방이 될 사람을 위하여 특별대리인을 선임할 수 있다(민소 378조). 특별대리인의 선임에 관하여는 민사소송법 62조를 준용하면 될 것이다.

② 증명할 사실

③ 보전하고자 하는 증거

④ 증거보전의 사유

신청인은 이에 관한 소명자료를 신청서에 붙여야 하는데(민소규 124조 2항), 소명이 없는 경우에는 신청을 각하하여야 한다.

(2) 증거보전신청은 신청사건으로 전산입력한다(인지액·편철방법예규).

다. 비용의 예납

신청인이 소송구조를 받은 경우가 아니면 그 증거조사비용을 예납하여야 한다. 증거보전의 비용은 소송비용의 일부가 되므로(민소 383조), 그 부담은 소송비용의 재판에서 일괄하여 정하여진다. 증거보전으로 증거조사가 되었지만 본안소송이 계속되지 아니한 때에는 민사소송법 114조의 규정에 준하여 비용의 부담을 정함이 상당하다.

라. 결 정

증거보전의 신청에 대하여 법원은 그 허부의 재판을 하여야 한다. 이 재판은 변론 없이 결정으로 한다. 증거보전신청을 받아들이는 결정에 대하여는 불복신청을 하지 못하지만(민소 380조), 이를 각하·기각하는 결정에 대하여는 신청인이 항고할 수 있다(439조). 따라서 증거보전신청을 각하·기각한 결정은 민사소송법 449조의 특별항고의 대상이 아니다(대법원 2018. 3. 27. 자 2017그758 결정). 이론적으로는 증거보전을 허용하는 재판과 증거조사를 실시하는 결정은 별개이나 증거보전결정[전산양식 A1860]과 같이 하나의 결정서를 작성하여도 무방하다. 증거보전을 허용한 결정 자체에 대하여는 불복할 수 없지만, 그에 기하여 증거조사를 실시하는 결정으로서 법원이 문서제출을 명한 경우에 이에 대하여 불복이 있는 이해관계인은 즉시항고를 제기할 수 있다(대법원 2012. 3. 20. 자 2012그21 결정). 위와 같이 즉시항고가 허용되는 경우에는 민사소송법 449조에 규정된 특별항고를 제기할 수 없으므로, 증거보전신청을 허용하는 취지에서 한 문서제출명령에 대해 불복한다는 취지로 즉시항고장을 제출한 것을 특별항고로 보아 대법원에 기록을 송부한 것은 잘못이다(대법원 2023. 9. 4. 자 2023그676 결정). 증거보전결정은 원칙적으로 양쪽 당사자와 증거조사를 받게 되는 제3자에게 고지되어야 하지만,

급속을 요하는 경우 등에는 그러하지 아니하므로(381조), 상대방에게 사후에 지체 없이 고지하면 족하다.

[전산양식 A1860] 증거보전결정

○ ○ 법 원

결 정

사 건 20 카기○○ 증거보전

신 청 인 ○○○

상 대 방 ○○○

주 문

1. 이 사건에 관하여 증인 ○○○을 신문한다.
2. 증인신문기일은 20○○. ○. ○. : 로 지정한다.

이 유

신청인의 이 사건 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20○○. ○. ○.

판 사 ①

마. 증거조사의 시행

(1) 증거보전절차에서의 증거조사도 민사소송법과 민사소송규칙 중 증거에 관한 규정이 적용되어 본안소송에서의 증거조사와 동일한 방법으로 시행된다(민소 375조, 민소규 123조). 각종 증거조사조서의 작성도 마찬가지로, 법원 밖에서의 증거조사의 경우에 적용되는 조서작성례에 따라 작성한다.

증거목록의 작성 여부는 다음과 같다.

- ① 법원 밖 서증조사를 행한 경우 및 문서제출명령이나 문서송부촉탁에

의하여 문서가 제출 또는 송부된 경우에는 서증목록을 작성한다. 서증번호는 임시번호의 의미로(후에 본안소송에서 새로운 번호가 붙을 때까지) 붙여서 기재해 둔다.

② 증인신문·감정·문서제출명령·문서송부촉탁·검증·당사자신문 등을 행한 경우에는 시행한 증거의 종류가 많아서 특히 복잡한 경우에만 증인등 목록을 작성하고, 한두 가지에 그칠 경우에는 증인등목록을 작성할 필요가 없다.

(2) 증거조사기일은 신청인과 상대방에게 통지하여야 하나, 긴급한 경우에는 예외로 한다(민소 381조). 조사하여야 할 증인이나 감정인이 있으면 출석을 요구하여야 함은 물론이다.

(3) 증거보전절차에서 신문한 증인을 당사자가 변론에서 다시 신문하고자 신청한 때에는 법원은 그 증인을 신문하여야 한다(민소 384조).

4. 증거보전기록

가. 보 관

증거보전기록이란 증거보전절차에 관련된 모든 서류를 편철하여 민사신청 사건기록표지를 붙인 기록을 말한다. 이 기록은 본안소송의 수소법원이 스스로 증거보전절차를 행한 경우에는 본안소송의 기록에 첨철하고(인지액·편철방법예규), 그 밖의 경우에는 다음에서 설명할 송부가 있기까지 증거조사를 행한 법원의 법원사무관등이 별책으로 보관하여야 한다.

나. 송 부

소제기 전에 증거보전절차를 시행하였거나 소제기 후라도 수소법원이 아닌 법원에서 증거보전절차를 시행한 경우에는 증거보전법원과 수소법원이 다르게 되는데, 이 경우 증거보전법원은 수소법원(본안소송의 기록이 있는 법원)으로 증거보전기록을 보내야 한다(민소 382조).

소제기 전에 증거보전을 위한 증거조사가 이루어진 때에는 당사자는 소장에 증거조사를 한 법원과 증거보전사건의 사건번호·사건명을 적어야 한다(민소규 62조의2). 위와 같은 사항이 기재된 소장을 접수받은 법원 또는 소제기 후에 당사자로부터 이를 통지받은 법원은 증거보전법원에 그 기록의 송부요청을 하여야 한다. 이때의 송부요청은 문서송부촉탁(민소 352조)이 아니므로 문서송부촉탁서에 의할 것이 아니고 기록송부요청서[전산양식 A1861]에 의하여야 한다.

소송계속 후 증거보전에 따른 증거조사를 하거나 증거보전의 신청이 있었으나 증거조사가 마쳐지기 전에 본안소송이 제기된 경우, 증거보전에 관한 기록은 증거조사를 마친 후 2주 안에 본안소송의 기록이 있는 법원에 보내야 한다(민소규 125조 1항). 한편 증거보전에 따른 증거조사를 마친 후에 본안소송이 제기된 때에는 본안소송이 계속된 법원으로부터 송부요청을 받은 날부터 1주 안에 증거보전에 관한 기록을 보내야 한다(2항). 당사자가 본안소송 계속 법원에 송부요청의 신청을 하지 아니하고 증거보전법원에 직접 송부신청을 하는 경우에도 그 신청 시부터 1주 안에 본안소송 계속 법원으로 송부하여야 한다. 증거보전에 따른 증거조사가 실시되지 아니한 경우에는 위 절차가 적용되지 아니하므로, 본안소송에서 증거보전기록이 필요한 당사자는 민사소송법 352조가 규정하는 문서송부촉탁의 신청을 하여야 한다.

증거보전법원은 당사자의 신청·통지 또는 수소법원의 기록송부요청이 있으면 기록송부서[전산양식 A1862]를 붙여서 증거보전기록을 송부한다. 따로 송부결정을 할 필요는 없다. 위와 같이 송부된 증거보전기록은 본 소송기록에 첨부하여야 한다.

5. 변론에의 상정과 조서 기재

가. 변론에의 상정

소송계속 전에 수소법원 이외의 법원에서 시행된 증거보전결과는 물론이

거니와 소송계속 후에 수소법원 스스로 시행한 증거보전의 결과(증거보전 신청사건은 본안소송의 담당부에 배당되는 것이 통례이다)도 변론에 상정되지 아니하면 증거자료로 사용할 수 없다.

이 경우에는 증거보전절차가 종료되어 수소법원에 그 기록이 송부된 후의 변론(준비)기일에 “원고, 증거보전결과 원용”의 형식으로 변론(준비기일)조서(기본조서)에 기재한다. 양쪽 당사자 모두 원용하지 않는다는 의사를 표명한 경우에는 “재판장, 증거보전기록을 제시, 양쪽 당사자, 위 증거보전결과를 원용하지 않는다고 진술”이라고 기재한다.

나. 증거목록의 기재

증거보전절차에 의하여 증거조사(예: 증인신문)를 한 경우에, 위와 같은 변론에의 상정을 거쳐 증거로 되는 것은 조사된 형태대로의 증거 그 자체(예: 증언)이지, 증거조사조서(예: 증인신문조서)가 서증으로 되는 것이 아니다. 따라서 증거보전절차에서의 증거조사과정을 ‘민사 등 증거목록에 관한 예규’에서 정한 바에 따라 본안소송기록의 증거목록에 이기(移記)한다. 종이기록의 경우 그 기재방식은 다음과 같다.

(1) 법원 밖 서증조사, 문서제출명령, 문서송부촉탁의 경우

증거보전으로 법원 밖 서증조사, 문서제출명령, 문서송부촉탁을 시행하여 서증이 제출된 경우에는 위 증거조사 자체에 관한 증인등목록은 기재하지 않고 제출된 서증에 관한 서증목록만을 작성한다(민사증거목록예규 6조 1항). 서증목록의 ‘기일 및 장수’란에는 “증거보전”, “첨철”이라고 기재하고(10조 1항 3호, 2항 2호), ‘비고’란에 송부한 법원, 증거조사방법과 도착일자를 “○○법원, 법원 밖 서증조사(문서제출명령, 문서송부촉탁), 20○○. ○. ○. 도착” 또는 “○ ○법원, 송부기록 중 일부, 20○○. ○. ○. 도착” 방식으로 기재한다(20조 8호).

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
2	증거보전	건물임대차 계약서	1차	부 지	○○법원 법원 밖 서증조사 2025. 8. 14. 도착
	첨철				

(2) 검증·감정·증인신문 등의 경우

증거보전으로 위 (1)항 이외의 증거방법에 대한 증거조사를 시행한 경우에는 본안기록의 증인등목록의 ‘증거조사’란 및 ‘증거방법’란에는 통상의 증거조사에 준하여 그 내용을 기재한다(민사증거목록예규 6조 2항, 19조 4항). 다만 ‘기일 및 장수’란에는 “증거보전”, “첨철”이라고 기재하고(16조 1항 3호, 2항 2호), ‘증거결정’란에는 “증거보전”이라고 기재하며, ‘비고’란에는 송부한 법원과 도착일을 기재한다(20조 8호).

[기재례]

기일 및 장 수	증거 방법	증 거 결 정		증거조사	비 고
		기 일	채 부		
증거보전	검증(현장)	증거보전	채 부	2025. 6. 5. 14:00 (식시)	○○법원 2025. 8. 14. 도착
첨철					
증거보전	감정(측량)	증거보전	채 부	"	"
첨철					
증거보전	증인 ○○○	증거보전	채 부	2025. 7. 10. 14:00 (식시)	○○법원 2025. 8. 14. 도착
첨철					